

1500621-12.2021.8.26.0575

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marcelo Luiz Leano

Comarca: São José do Rio Pardo

Foro: Foro de São José do Rio Pardo

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 24/01/2022

... disso, havia denúncia no sentido de que o Réu praticava o tráfico de drogas. A existência desses elementos na residência do acusado indica que ele se dedicava ao comércio de drogas. Não se trata, tendo em vista a quantidade das drogas apreendidas, os petrechos usados para o tráfico e o dinheiro recolhido, de tráfico pontual ou isolado exercido pelo Réu, não sendo o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Pardo

Foro de São José do Rio Pardo

2ª Vara

Praça dos Três Poderes, nº 3, Sao Jose do Rio Pardo-SP - cep 13720-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500621-12.2021.8.26.0575 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500621-12.2021.8.26.0575

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2210574/2021 - DEL.INV.GER. CASA BRANCA, 19428007 - DEL.INV.GER. CASA BRANCA, 85/21/212 - DEL.INV.GER. CASA BRANCA, 2210574 - DEL.INV.GER. CASA BRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MICHAEL FERNANDO DIOGO DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Dr. Marcelo Luiz Leano

Vistos.

MICHAEL FERNANDO DIOGO DA SILVA, qualificado nos autos em epígrafe, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, conforme consta da peça acusatória, no dia 05 de agosto de 2021, por volta das 06h, no Sítio Venerando, Estrada Vicinal do Venerando, neste município e comarca, guardava e tinha em depósito, para fins de comércio, 28 tabletes, tipo tijolo, de Cannabis sativa L, popularmente conhecida como maconha, com peso aproximado de 17,31108 kg, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Auto de Prisão em Flagrante (fls. 01).

Prisão em flagrante convertida em preventiva em mesma ocasião em que determinada a destruição das drogas apreendidas (fls. 80/84).

Notificado (fls. 139), o acusado apresentou defesa escrita (fls. 175/179).

Impetrados Habeas Corpus (fls. 142/153), cujas liminares foram indeferidas (fls. 154/161 e 192/195).

Mantida a prisão cautelar do réu em análise ao disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal (fls. 206/208).

O réu foi citado (fls. 228).

Durante a instrução do feito, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e interrogado o acusado (cf. mídia digital armazenada no sistema SAJ).

Encerrada a instrução, em sede de alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência do pedido punitivo vestibular a fim de se condenar o acusado nos exatos termos da denúncia (fls. 254/261).

A Defesa, por sua vez, requereu por sua improcedência e consequente absolvição do réu, ante a ausência de provas de que este concorreu para a prática do crime, nos termos do artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal; ou, ainda, a desclassificação de delito para aquele previsto no artigo 28 do mesmo códex quanto às substâncias ilícitas encontradas no interior da residência do acusado.

Subsidiariamente, pleiteou seja a pena fixada no mínimo legal e que o acusado seja beneficiado com o redutor de pena previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 (fls. 262/272).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão estatal punitiva é procedente.

A materialidade do delito está estampada nas provas arregimentadas, notadamente no auto de exibição e apreensão de fls. 55/56; bem como nos laudos químicos-toxicológicos amealhados às fls. 110/121 e 242/244, provas técnicas a constatarem se tratar de substâncias de uso e comércio proscritos pela legislação brasileira.

A autoria também é certa e recai sobre o acusado, demonstrada pelas provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O réu sustentou não reconhecer o celular que foi a ele imputado nas investigações, alegando ter perdido um aparelho celular há cerca de 05 meses. Informou que não tem ligação com as drogas, muito menos com as pessoas investigadas. Michael disse ser usuário de maconha, sente vergonha disso, e que a droga encontrada na caixa da privada era realmente sua, porém, reiterou que as outras drogas encontradas não são de sua posse. O motivo de ter quebrado o celular, o réu esclareceu que participou de uma briga com sua esposa, e que por ciúmes, resolveu danificar o próprio celular para sanar tal problema; e, além disso, suas crianças sempre mexiam em seu aparelho, sendo esse outro motivo do aparelho ter estragado. Após os policiais cumprirem o mandado e pedirem seu celular, o acusado deu de boa vontade o aparelho e não o quebrou propositalmente. Em relação ao número grampeado e o IMEI que eram relacionados a ele, negou novamente que o aparelho era seu. Apresentada uma imagem de uma mão segurando um tablete de maconha, obtida pelo IMEI do celular interceptado, o acusado estendeu sua mão esquerda para comparação entre aquela da imagem e a sua e, segundo Michael e seu defensor, não se tratava de mesmo membro. Indagado, por fim, se a residência demonstrada na primeira foto era de Michael e, se a vegetação onde foram encontradas as drogas era próximo a sua casa, o réu confirmou todas as alegações, dizendo, ainda, que o acesso a sua residência era livre, onde qualquer pessoa podia ingressar, inclusive reclamou com o dono do local sobre o tráfego intenso de pessoas estranhas (cf. mídia digital armazenada no sistema SAJ).

Todavia, certo é que, confrontando sua versão com as demais provas do processo, conclui-se que ela não apresenta qualquer embasamento probatório, conforme se vê. Ouvido em juízo, o PC Welther Vaz Martins relatou tratar-se de uma investigação que visava apurar uma organização criminoso, atuante na região do Vale do Redentor, em São José do Rio Pardo. Após algumas prisões em flagrante e apreensões de menores

infratores, identificaram alguns possíveis autores e fizeram requerimento para autoridade judicial, pedindo a expedição de mandado de busca. Em uma dessas buscas, na casa de Marcos, vulgo "Abacaxi", foi encontrada uma porção de maconha já fracionada em pedaços de 50g, além de um aparelho celular, e, com autorização judicial, esse aparelho foi periciado. Na análise, foram encontradas trocas de mensagens entre "Abacaxi" e o suposto patrão de toda organização, "Alexin". O assunto dessas mensagens era sobre onde as drogas estavam armazenadas, os tablets não fracionados. Após isso, em troca de mensagens, o "Abacaxi" entrou em contato com Michael marcando de se encontrar na residência rural do acusado. Logo pela manhã a PC cumpriu o mandado de busca e apreensão na residência rural de Michael e, dentro da casa, encontraram uma porção de 50g de maconha. Com a ajuda de cães farejadores, foram encontrados, ainda, enterrados nos arredores da residência, 27 tablets da mesma droga, com peso aproximado de 17 quilos. Em entrevista informal junto ao setor de investigação, Michael assumiu que estaria de fato guardando a droga e que receberia, desse armazenamento, uma quantia de R\$ 400,00 por mês. Esclareceu, ainda, o policial, que, quando cumprido o mandado de busca, as interceptações telefônicas já haviam se encerrado, não podendo confirmar com convicção de que o número de IMEI usado em conversa com "Abacaxi" pertencia efetivamente ao réu (cf. mídia digital armazenada no sistema SAJ).

Em mesmos termos foram as alegações do PC Artibano José Cruz. Narrou ter participado da operação, realizada pelo serviço de inteligência, com um levantamento por ele e sua equipe para descobrir onde era o sítio "Venerando", residência do acusado. Posteriormente, o policial auxiliou no cumprimento do mandado de busca, oportunidade em que, dentro da caixa de descarga, localizaram uma pequena porção de maconha, cerca de 57g de maconha, e apreenderam também um celular, que foi danificado propositalmente pelo acusado. Em seguida, com ajuda de cães farejadores, encontraram um tambor coberto por folhas em que foi localizado 27 volumes de maconha pesando cerca de 17 quilos. Indagado sobre as drogas, Michael relatou que as substâncias eram de Alex, Andy e Ruivo (cf. mídia digital armazenada no sistema SAJ).

Lado outro, ouvida a testemunha arrolada pela defesa, Heberson Andrade Coelho, relatou conhecer Michael há um bom tempo, pois moravam próximos. O réu sempre foi muito trabalhador, prestativo e nunca foi envolvido com nada ilegal. Perguntado sobre o acesso da zona rural em que viviam, afirmou ser de fácil ingresso, inclusive com grande tráfego de pessoas, cuja rodovia que liga São José do Rio Pardo a Mococa fica localizada bem próxima. Ainda, indicou a distância da residência do réu e a localização das drogas encontradas, mencionando ser cerca de 150m (cf. mídia digital armazenada no sistema SAJ).

Po fim, Maurício Cattaruzzi, outra testemunha arrolada pela defesa, alegou ter conhecido Michael na igreja a qual os dois frequentam. Conhece a zona rural em que o réu reside e, segundo a testemunha, trata-se de local conhecido, de livre acesso e intenso tráfego, com estrada de passagem de trânsito livre. Em relação a vida de Michael, relatou que o acusado participava da comunidade religiosa, é casado, possui filhos, é trabalhador, bom marido e bom pai (cf. mídia digital armazenada no sistema SAJ).

Conquanto o réu tenha negado conhecimento sobre as substâncias ilícitas encontradas ao redor de sua residência, alegando, ainda, as testemunhas arroladas pela defesa que o local em que encontraram as drogas tratava-se de local de fácil acesso a qualquer transeunte, certo é que referidos relatos vão de encontro ao exposto nos autos.

De proêmio, o encontro das referidas substâncias originou do cumprimento de mandado de busca na residência do réu, proveniente de uma investigação da quebra de sigilo telefônico do aparelho celular apreendido em poder de vulgo "Abacaxi", de onde extraíram conversa com outro aparelho celular de um outro indivíduo relativa ao local de armazenamento dos entorpecentes. Embora não haja certeza de que esse outro celular pertença ao acusado, a ser melhor apurado nos autos que investiga uma associação criminosa destinada ao tráfico de drogas, o envolvimento de Michael com a mercancia espúria restou inequívoca.

Os agentes policiais aduziram que, após investigação sobre a movimentação de

entorpecentes na cidade, concluíram como ponto de armazenamento a residência de Michael e, em diligência à propriedade, encontraram expressiva quantidade de maconha.

Convém destacar que não há, nos autos, qualquer contraprova a desacreditar os depoimentos dos policiais, que foram harmônicos entre si, mantendo a mesma versão em todas as ocasiões em que foram ouvidos, sendo que meros desencontros sobre circunstâncias acessórias não retiram a credibilidade que merece a prova testemunhal produzida nos autos.

Destarte, prevalecem os testemunhos por eles prestados, eis que, de modo algum, estavam impedidos de depor ou eram testemunhas suspeitas. O depoimento de policiais tem plena força probante, sendo que somente a contraprova poderia infirmá-los como prova bastante à condenação, contraprova esta inexistente no feito.

Destarte, os depoimentos colhidos pelos policiais e a expressiva quantidade de drogas apreendidas revelam a conduta delituosa intencional do acusado em traficar entorpecentes.

Cumpra asseverar que a infração penal de tráfico de drogas é crime de ação múltipla e conteúdo variado, bastando que o agente pratique, intencionalmente, qualquer um dos verbos nucleares previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, como, no caso, "guardar" e "ter em depósito" 28 tabletes, tipo tijolo, de maconha, com peso aproximado de 17,31108 kg, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Inconteste, portanto, reconhecer a prática do delito narrado na exordial acusatória pelo acusado.

Assim, provadas a autoria e a materialidade delitivas e, não havendo causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, a condenação é medida que se impõe.

Nos termos do artigo 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, de acordo com o disposto no artigo 42 da Lei de Drogas, prepondera sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. In casu, há de se considerar a quantidade de entorpecentes apreendida nestes autos, incomum a esta urbe. Assim, fixo a pena-base em 1/6 acima de seu mínimo legal, fixando-a em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes a serem valoradas, mantendo-se a pena no patamar acima estabelecido.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento de pena. Também inexistem causas de diminuição de pena a serem valoradas, pois o réu não se beneficia da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, calcada na primariedade e bons antecedentes do acusado que não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa.

No caso, o réu não preenche os requisitos legais, já que a benesse penal em questão é dirigida a pessoas que se envolveram com a traficância de forma pontual, ocasional, e, embora o acusado seja primário, é de se considerar a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidas, se não a maior apreensão até hoje realizada nesta comarca, tratando-se de hipótese para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal ora analisado.

A respeito, tem-se o precedente do STF:

Não é crível que o réu, surpreendido com mais de 500 kg de maconha, não esteja integrado, de alguma forma, a organização criminosa, circunstância que justifica o afastamento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas (STF. 1ª Turma. HC 130981/MS, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 18/10/2016). (...) In casu, a paciente, na condição de "mula", foi surpreendida transportando expressiva quantidade de droga ao exterior. Tal fato afasta o preenchimento dos requisitos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas (...) - STF. 1ª Turma. HC 123430, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 14/10/2014.

Ainda, sobre o tema:

" (...) Outrossim, há que se considerar que na residência do Réu foram encontrados os seguintes produtos: (i) 179 fraconetes plásticos contendo cocaína, pesando cerca de 200g, (ii) uma porção de cocaína com peso aproximado de 39g, (iii) 19 tijolos de Cannabis sativa L, droga conhecida como maconha, pesando cerca de 2,059kg, (iv) 3 balanças de precisão, (v) 5 rolos de plástico filme, normalmente utilizado para embalar drogas, (vi) 2 aparelhos celulares e (vii) R\$ 650,00 em dinheiro. Além disso, havia denúncia no sentido de que o Réu praticava o tráfico de drogas. A existência desses elementos na residência do acusado indica que ele se dedicava ao comércio de drogas. Não se trata, tendo em vista a quantidade das drogas apreendidas, os petrechos usados para o tráfico e o dinheiro recolhido, de tráfico pontual ou isolado exercido pelo Réu, não sendo o caso, portanto, de aplicação do chamado tráfico privilegiado. Nesse mesmo sentido, Renato Brasileiro: (...) se o indivíduo for flagrado com grande quantidade e variedade de drogas, tem-se aí forte indicativo de que se trata de agente dedicado a atividades criminosas, até mesmo porque não é normal que um traficante pequeno e eventual dê início às atividades de traficância com tamanha quantidade e diversidade de drogas (Legislação criminal especial comentada: volume único / Renato Brasileiro de Lima - 4 ed. - Salvador: JusPODIVM, 2016).".

No mesmo sentido são os seguintes entendimentos do Superior Tribunal de Justiça: 6ª Turma HC 174.547/SP, Rel Min Og. Fernandes, j. 17.02.2011, DJE 07/12/2011 e 5ª Turma, HC 148.148/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 26.11.2009, DJE 15/12/2009.

Diante de tais considerações, é de se afastar a incidência, em concreto, da causa de diminuição em tela, mantendo a pena no patamar fixado.

Mesmo para os crimes hediondos ou a eles equiparados cometidos na vigência da Lei nº 11.464/2007, a fixação do regime inicial de cumprimento de pena deve levar em consideração a quantidade da pena imposta, a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como as demais peculiaridades do caso concreto, para que, então, seja escolhido o regime carcerário que se mostre o mais adequado para a prevenção e repressão do delito perpetrado (HC n. 273.348/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 27/2/2014).

In casu, fixo o regime inicial de cumprimento de pena em fechado. A fixação do regime mais gravoso é imposta no caso em tela, considerando suas peculiaridades. Trata-se de quantidade incomum de entorpecentes localizada, vislumbrando um maior envolvimento do acusado com a mercancia espúria.. Assim, o regime mais gravoso é de rigor no caso, sendo regime mais brando incompatível com a gravidade concreta dos fatos.

Nesse sentido, têm-se julgados do E. Tribunal de Justiça deste Estado: Apelação nº 0001994-15.2011.8.26.0443, 4ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Luis Soares de Mello, j. 26.06.12, e Apelação nº 0011197-28.2006.8.26.0038, 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Roberto Midolla, j. 28.06.12.

O valor de cada dia-multa será de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, à míngua de maiores elementos sobre a capacidade financeira do réu.

Assim, fica o réu definitivamente condenado à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no patamar estabelecido.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, uma vez que a pena aplicada é superior a 04 (quatro) anos, o que impede a concessão da benesse, nos termos do artigo 44, inciso I, do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão estatal punitiva, para CONDENAR o réu MICHAEL FERNANDO DIOGO DA SILVA como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no patamar estabelecido.

O acusado respondeu a este processo preso e nada há nos autos que altere o referido

cenário. Conforme a determinação do artigo 387, §1º, do Código de Processo Penal, não concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade em relação aos fatos aqui apurados, uma vez que a permanência dele no cárcere é necessária para a manutenção da ordem pública. Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, o fumus comissi delicti decorre da própria procedência da pretensão punitiva veiculada na denúncia, havendo prova da materialidade e indícios de autoria do crime atribuído. O periculum libertatis, por sua vez, é evidenciado pela gravidade em concreto do crime praticado pelo réu, evidenciada pela expressiva de quantidade de entorpecentes a ele vinculado, além do risco concreto de ele voltar a delinquir, bem como da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que não existem garantias de que em liberdade não se afastarão do distrito da culpa. Recomende-se ao cárcere em que se encontra e expeça-se guia de execução provisória. Tendo em vista que o artigo 91, inciso II, do Código Penal e o artigo 63, §1º, da Lei nº 11.343/06 estabelecem que os valores e bens apreendidos em razão do tráfico de drogas serão perdidos em favor da União, decreto o perdimento dos bens apreendidos em poder do réu em favor da União. Oficie-se ao Fundo Nacional Antidrogas (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas para as providências cabíveis.

À vista dos Habeas Corpus impetrados nos autos (fls. 142/153), cujas liminares foram indeferidas (fls. 154/161 e 192/195), pendentes de julgamento, oficie-se com urgência ao Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo e Colendo STJ para conhecimento do aqui deliberado.

Após o trânsito em julgado, comunique-se ao Cartório Distribuidor, ao IIRGD e ao TRE.

Custas na forma da lei.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo-se as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.I.C.

Sao Jose do Rio Pardo, 21 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA